

1500435-70.2022.8.26.0666

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: Artur Nogueira

Foro: Foro de Artur Nogueira

Vara: 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Nefi Cordeiro, DJe 17/11/2016.

TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes.

Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Artur Nogueira

Foro de Artur Nogueira

Vara Única

Rua 13 de Maio, 140, Artur Nogueira-SP - cep 13160-170

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500435-70.2022.8.26.0666 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500435-70.2022.8.26.0666

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2081757/2022 - DEL.POL.ARTUR

NOGUEIRA, 23838416 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA, 788/22/309 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA,

2081757 - DEL.POL.ARTUR NOGUEIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GINALDO DE JESUS SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de GINALDO DE JESUS SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33, "caput" c/ art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 afirmando que em 24 de março de 2022, às 06h30, na Rua Ernesto Bôer, n. 273, Bairro Itamaraty, CEP 13160-000, nesta Cidade e Comarca de Artur Nogueira, guardava, envolvendo adolescentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 395 (trezentos e noventa e cinco) eppendorfs de cocaína, 02 (duas) porções de cocaína, 01 (um) tijolo de maconha e 01 (uma) porção de maconha pesando, ao todo, 729g (setecentos e vinte e nove gramas).

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, o denunciado

guardava, em um terreno baldio ao lado de sua residência, 395 (trezentos e noventa e cinco) eppendorfs de cocaína, 02 (duas) porções de cocaína, 01 (um) tijolo de maconha e 01 (uma) porção de maconha os quais pesavam, respectivamente, 9,8g (nove gramas e oito decigramas), 25,8g (vinte e cinco gramas e oito decigramas), 162g (cento e sessenta e duas gramas), 524g (quinhentos e vinte e quatro gramas) e 7,4g (sete gramas e quatro decigramas).

As drogas localizadas com o acusado eram destinadas ao tráfico de entorpecentes praticado por um grupo que arregimentava adolescentes a fim de que eles comercializassem drogas valendo-se de sua inimputabilidade. A Polícia Civil, em cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão emitido no Inquérito Policial n. 1500410-57.2022.8.26.0666 seguiu à residência do acusado e localizou R\$ 14.780,00 (catorze mil, setecentos e oitenta reais) em dinheiro com odor característico de maconha. Havia no local uma balança de precisão e embalagens para drogas. Com a chegada de um cão farejador, foram identificados em um terreno baldio ao lado da residência do acusado 395 (trezentos e noventa e cinco) eppendorfs de cocaína, 02 (duas) porções de cocaína, 01 (um) tijolo de maconha e 01 (uma) porção de maconha os quais pesavam, respectivamente, 9,8g (nove gramas e oito decigramas), 25,8g (vinte e cinco gramas e oito decigramas), 162g (cento e sessenta e duas gramas), 524g (quinhentos e vinte e quatro gramas) e 7,4g (sete gramas e quatro decigramas). A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

No caso em exame, há prova da existência do crime e de sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 15/20), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21/23), pelos laudos periciais (fls. 108/177) que resultaram positivos para as drogas encontradas e, sobretudo, pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

A testemunha de acusação, o investigador de polícia, GABRIEL DE QUEIROZ, na fase policial, disse que participou da "OPERAÇÃO PISTRINUM", a qual derivou de uma Investigação contra o tráfico de drogas no bairro Itamaraty. Contou que durante as investigações recebeu testemunhos de muitos populares, bem como acompanhou em alguns dias a movimentação dos suspeitos. Informou que havia denúncias de que GINALDO foi avistado por populares deixando um terreno não habitado próximo de sua casa com um pacote em mãos, tendo desde então a Investigação se atentado para as imediações da casa de GINALDO. Disse que durante as últimas semanas, alguns indivíduos presos por tráfico de drogas no bairro confidenciaram que GINALDO entregava os entorpecentes já prontos para a venda na própria padaria, sempre em números pares. Narrou que, nesta data, diligenciou juntamente com outros policiais, e uma equipe da guarda municipal no apoio, para cumprir os mandados de busca e apreensão e de prisão temporária relacionados à GINALDO DE JESUS SILVA. Informou que antes de irem até o endereço do Indiciado, foram até a padaria a qual este é proprietário, uma vez que nos trabalhos de investigação foi observado que GINALDO costumava chegar pouco após as 05h da manhã no local; que lá chegando, de fato avistaram GINALDO no interior do estabelecimento, tendo a equipe prontamente adentrado o local e abordado o Indiciado, que foi comunicado que havia um mandado de prisão em seu desfavor; que então conduziram GINALDO até seu endereço na Rua Ernesto Boer, 273, para que acompanhasse as buscas; que ao chegarem no local, fizeram contato com RENATA DA SILVA LIMA, esposa do Indiciado, que então passou a acompanhar as buscas; que logo no início GINALDO já afirmou que havia uma vultosa

quantidade de dinheiro em espécie em um armário, aproximadamente R\$ 14 mil; Que durante as buscas pelos cômodos da casa nada de ilícito foi localizado, porém de fato foi localizada uma grande quantidade em dinheiro; que percebeu que um dos "pacotes" de notas possuía um leve odor característico de entorpecentes; que então em certo momento, a equipe do Canil da guarda municipal chegou para apoiar a ação; que ao lado da casa de GINALDO, há um terreno com um alguns plantios de vegetais; que após alguns minutos, através da indicação do cão farejador, guardas adentraram tal terreno e verificaram uma pilha de tijolos há poucos metros de sua entrada, sendo encontrado então expressiva quantidade de eppendorffs pretos com cocaína já embalados e separados em "kits" prontos para a venda, um tijolo de substância esverdeada com odor de maconha, uma pequena porção de maconha e 02 saquinhos com um pó branco aparentando ser cocaína diluída, bem como uma pequena balança de precisão; que imediatamente questionou GINALDO quanto ao que foi encontrado, tendo este alegado que desconhecia os objetos; que também foi apreendido no local o celular de GINALDO e de RENATA, e conduziram o investigado até esta Delegacia, para as providências de Polícia Judiciária, cabíveis ao evento. Em juízo, manteve sua versão.

A testemunha de acusação, MAURO CÉSAR DIONIZIO, disse que é Guarda Municipal e na data de hoje, foram dar apoio à Polícia Civil de Artur Nogueira para cumprimento de mandados de buscas domiciliar e de prisão temporárias, nos endereços mencionados nesta ocorrência. Relata que chegando na residência do suspeito, Ginaldo, já de muito conhecido nos meios policiais, e verificaram que ele não se encontrava no local e se deslocaram até a Padaria de sua propriedade. Chegando na Padaria, ele foi localizado e abordado, foi dado ordem de prisão ao investigado, e ato contínuo, ele foi conduzido até sua residência para que lá fossem feitas as buscas. Ao chegar na residência nada foi encontrado de ilícito, somente o valor de R\$ 14.780,00 (quatorze mil setecentos e oitenta reais) em espécie. Em seguida foi acionado o canil, tendo em vista que o investigador Gabriel possuía informações de que no terreno, localizado ao lado de sua residência, poderiam haver drogas. Após a chegada do canil, o portão do terreno foi aberto pelos policiais presentes, e o cão farejador encontrou as drogas, que estava em uma pilha de blocos, ao lado do muro que divide a casa, sendo as drogas do investigado Gil. Diante disso o investigado foi encaminhado a esta Delegacia de Polícia para que a Autoridade Policial tomasse as medidas de polícia judiciária cabíveis. Em juízo, disse, no dia da ocorrência contra Ginaldo, eles foram acionados pela polícia civil para dar apoio para o mandado de busca e apreensão em várias residências do Itamarati. Foram até a padaria onde foi encontrado o investigado e após o ser preso o conduziram até sua residência. A esposa de Ginaldo encontrava-se na residência e foi ela quem abriu o portão, foi informado por Ginaldo aos policiais que na residência tinha um valor de quase quinze mil em dinheiro e após a busca dentro da residência nada de ilícito foi localizado, o investigador tinha informações de que a droga era mantida no terreno ao lado da residência e por isso foi acionado o canil da guarda municipal, após as buscas no terreno foi localizado os entorpecentes, então o investigado foi conduzido a delegacia onde tomaram as medidas cabíveis. Perguntado disse que efetuou juntamente com a polícia civil as buscas dentro da residência nos quartos e que durante as buscas eles já tinham a informação de que as drogas poderiam estar no terreno ao lado, relatou que no dia da ocorrência primeiramente eles se dirigiram a residência de Ginaldo antes de irem até a padaria sendo a abordagem realizada por outros policiais. Perguntado não se recordou se o veículo do investigado foi conduzido até sua residência, não se recordando também quanto tempo levou entre a busca dentro da residência e o acionamento do canil, não sabendo dizer se Ginaldo tinha algum problema pessoal com algum dos guardas. Perguntado disse que o investigado já foi abordado várias vezes mais devido a denúncias efetuadas contra ele, relatou que geralmente existe um relatório após efetuarem uma abordagem. Perguntado disse que já houve várias denúncias de tráfico de drogas envolvendo Ginaldo, inclusive dos próprios traficantes. Perguntado disse que não tem conhecimento de que o investigado já foi arrolado como testemunha de acusação contra alguns guardas, também não tendo conhecimento do suposto disparo de arma de fogo efetuado em frente a padaria durante alguma ocorrência.

A testemunha de acusação MARCELO FANTINI, guarda municipal, em juízo disse, que na data em que ocorreu a acusação de tráfico de drogas contra Ginaldo, ele foi solicitado pelo delegado de polícia de Arthur Nogueira, juntamente com a polícia civil onde se deslocaram até a residência e não o encontrando se dirigiram até a padaria onde Ginaldo foi encontrado. O delegado deu voz de prisão para ele e seguiram novamente até a residência dele para efetuar a busca domiciliar. Chegando ao local foi feito a busca, mas nada de ilícito dentro da residência foi localizado, somente uma quantia de R\$ 14.780,00. Foi acionado o canil, pois a polícia civil tinha informações de que poderia ter entorpecentes nos terrenos ao redor da residência. Com a chegada do canil, foi realizada a busca e localizado entorpecentes, diante dos fatos a autoridade se deslocou até a unidade policial. Perguntado disse que não participou das buscas no interior da casa, permanecendo com Ginaldo na garagem da residência. Quem realizou as buscas no interior da casa foi o delegado de polícia juntamente com um guarda municipal e o investigador. Perguntado disse que não houve nenhuma diligência em que a guarda municipal realizou sem supervisão. Perguntado relatou que a equipe do canil era composta por três pessoas e um cão farejador e que eles realizaram as buscas ao redor da residência juntamente com a polícia civil. Perguntado não soube dizer quem encontrou os entorpecentes. Perguntado disse que os entorpecentes foram encontrados em um muro paralelo a casa de Ginaldo sendo o acesso mais fácil ao local em que foi encontrado os entorpecentes pelo muro da casa do investigado. Perguntado relatou que os entorpecentes consistiam em pinos de cocaína e maconha. Disse que antes da operação já tinha ouvido diversos relatos de que Ginaldo e o irmão era envolvido com o tráfico de drogas, sendo as informações chegavam até a guarda por meio de denúncias anônimas, traficantes presos. Perguntado disse que o investigado fazia propostas para que adolescentes trabalhassem para ele sendo muito comum a apreensão de adolescentes. Perguntado disse que o guarda que estava conduzindo o cão farejador era o GCM Carneiro. Perguntado disse que tiveram uma ocorrência onde foi flagrado um traficante a duas quadras da padaria do investigado e que na tentativa de prisão o traficante conseguiu fugir e adentrou na padaria, em que Ginaldo negou-se a entregar o rapaz, foi então solicitado apoio e posteriormente a entrega do rapaz. Disse que não se recorda de ter ocorrido disparos de arma de fogo. Perguntado relatou que perto da residência do investigado existe outros terrenos baldios.

GINALDO DE JESUS SILVA, em seu interrogatório na fase policial, disse que é empresário, proprietário da padaria "São Sebastião" e que na data dos fatos, chegou na padaria de sua propriedade em torno de 05:20 horas, e que por volta das 05:40 horas, chegaram em seu estabelecimento, os policiais civis e guardas municipais, juntamente com a Autoridade Policial, e ao encontrá-lo no local, deram ordem de prisão ao interrogado e o informaram que estavam com mandado prisão e de busca e apreensão, autorizando tais buscas em sua residência e também na padaria. Neste momento, o interrogado foi algemado e levado até sua residência onde foi efetuado o cumprimento das buscas. O interrogado informa que em sua residência nada de ilícito foi encontrado, exceto o valor de R\$ 14.780,00 em espécie, onde informa ser fruto do seu trabalho na padaria, e que segundo ele, são feitos pagamentos em dinheiro aos seus fornecedores, motivo pelo qual ele guarda essa quantia em dinheiro em sua residência. O interrogado informa que ao final das diligências, os Guardas Municipais, que estavam com cão farejador, gritaram "bingo" e disseram que haviam encontrado as drogas no terreno ao lado de sua residência. Ao ser questionado se tais drogas eram sua, o interrogado negou veemente que estaria envolvido com o tráfico de drogas e que não seriam dele. O interrogado informa que o terreno ao lado de sua residência possui portão trancado com cadeado e que os guardas tentaram abri-lo testando todas as chaves que ele (interrogado) possuía, no entanto, nenhuma das chaves correspondia com o cadeado. O interrogado informa ainda que o terreno não é de sua propriedade e nem lhe pertence. Sobre os comprovantes de depósitos em nome de terceiros localizado em sua residência, disse que não se recorda de quem seja. Que após as diligências em sua casa nesta data, foi encaminhado até esta Delegacia de Polícia para ser ouvido sobre os fatos. Nega agressão dos agente durante as diligências. Em juízo, disse que não está envolvido com o tráfico de

drogas, sendo empresário e trabalhando honestamente. Na data dos fatos, disse que a polícia foi até a padaria onde efetuaram a sua prisão. Após Fantine e Mario desceram com ele em seu carro até sua residência para realizarem as buscas. Logo na chegada lhe foi perguntado se existia algo de ilícito na residência e ele respondeu que não, apenas tendo a quantia em dinheiro que foi encontrada. Só após um tempo de busca que os guardas encontraram os entorpecentes no terreno ao lado da residência, sendo que seu muro possui cerca de 3 metros de altura não tendo assim acesso ao terreno. Disse que sempre era ameaçado pelos guardas devido a desavenças que teve quando trabalhava na empresa Samaritá. Perguntado disse que a conversa que teve com sua filha, em que dizia que era envolvido com drogas é devido a uma ocorrência passada e já cumpriu sua pena por isso. Disse que é uma pessoa muito conhecida e que conhece muitas pessoas devido ao tempo em que mora no bairro, mas que isso não significa que seja traficante. Perguntado disse que durante a semana gastava em média com a padaria uma grande quantia, pois pagava diversos produtos em dinheiro, disse que vendia uma média de 2.000 pães ao dia.

Embora tenha negado os fatos, a versão dada pelo acusado não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isolada. Até porque foi incapaz de infirmar o restante do contexto probatório, que lhe é contrário, sequer apontando um motivo idôneo a motivar a prova oral colhida robusta trazida pela acusação ou explicar eventuais equívocos nas provas materiais.

Por outro lado, os depoimentos das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Não há nestes autos qualquer elemento para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, presentes o réu e seu defensor, tiveram estes plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o estado-juiz, dão conta das suas atividades. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada. STJ, HC 115516/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 03/02/2009.

"O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova". STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJE 17/11/2016.

TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS. Insuficiência de provas. Não configurado. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada, até mesmo pela divergência apresentada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Quantidade de droga, acondicionamento, que encaminham para o reconhecimento do

tráfico. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENCIA. Redução da fração utilizada. Redução da multa. Impossibilidade. Negado provimento do recurso. TJSP, Apelação n. 0042342-63.2009.8.26.0114, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro, j. 20.08.2013.

"No que tange ao valor probatório do testemunho dos policiais militares, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreitamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante".bTJSP, Apelação n. 0068618-51.2017.8.26.0050, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 08.08.2018.

A versão do réu restou isolada nos autos. Não só pelo encontro dos entorpecentes ao lado de sua residência, mas também pela ausência de comprovação da origem lícita do valor encontrado em sua residência.

Sem mencionar a própria confissão do acusado a sua filha afirmando a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Ademais, o acusado não soube explicar os motivos pelos quais era constantemente procurado por populares para resolução de questões pessoais, fato esse muito comum à traficantes que exercem autoridade e força nas comunidades que residem.

Por fim, não convence a versão do acusado de que tinha interesse nas atividades da polícia, pois temia represálias em vista de ter sido testemunha em um processo criminal ajuizado contra um guarda civil. Pelo conteúdo das mensagens obtidas, verifica-se que o réu tentava se prevenir de possível ação dos agentes públicos que levasse a descoberta da atividade ilícita.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

Passo a dosar a pena.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A definição de quais substâncias são consideradas ilícitas se encontra na Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998 (ver artigo 66 da Lei 11.343/06) e nesta definição se incluem todas as previstas no Anexo I (ver, p. ex., REsp.

1.444.537/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

Portanto, em referência ao critério da natureza da droga, por constarem da Lista F do Anexo I (substâncias de uso proscrito, ou seja, proibidas sob quaisquer circunstâncias ou concentrações pela natureza intrinsecamente nociva que possuem), merecem valoração nesta fase a maconha e cocaína, sendo que esta em especial (e em maior grau o crack, seu derivado), por causar severa dependência em seus usuários. O STJ, responsável pela uniformização da aplicação do direito infraconstitucional, tem entendido como razoável o aumento de um décimo na pena-base para quantias em torno de 100g de cocaína.

"No caso, observa-se que o Tribunal de origem, com fundamento o art. 42 da Lei de Drogas, elevou a pena-base em 1 ano, em razão da aferição desfavorável da quantidade e da natureza da droga (120 g de cocaína).

Tendo sido indicados elementos válidos para a majoração da reprimenda básica, uma vez que significativo o quantum e altamente nociva a substâncias apreendida, não se identifica a alegada contrariedade do art. 59 do CP, sobretudo quando tais circunstâncias foram elencadas legalmente como preponderantes, e as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas são de 5 a 15 anos de reclusão." STJ, HC 431541/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018.

Desta forma, a reprimenda pela maconha deve ser feita em patamar inferior e a valoração negativa pelo crack em patamar superior.

Assim, conjugando as drogas apreendidas com as quantidades encontradas, aplico um acréscimo de 1/6 nesta fase, resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de

reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segunda etapa. Não há circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência (certidão de objeto e pé de fls. 62/63), pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Terceira etapa. Ausentes causas de diminuição da pena. Incabível o redutor. As drogas foram apreendidas após cumprimento de mandado de busca motivados por denúncias aos policiais da cidade. Todo esse caminho, que foi da percepção dos populares, passando pela comunicação do delito aos servidores encarregados da segurança pública, diligências de investigação, solicitação da busca, terminando em cumprimento de mandado, revela a permanência e reiteração do agente no comércio ilícito denotando sua dedicação às atividades criminosas, o que é reforçado pela ausência de ocupação lícita regular.

Ausente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, vez que há nos autos comprovação do envolvimento ou da finalidade de visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação.

Fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento. Sendo o réu reincidente, em interpretação "contrario sensu" das alíneas "b" e "c" do §2º do art. 33 do Código Penal, o regime é, necessariamente, o fechado. Além disso, a reincidência constitui valoração gravemente negativa dos antecedentes do réu, que persistiu na vida do crime mesmo após sancionado severamente e, desta forma, nos termos do §3º do art. 33 do Código Penal também merece o regime inicial fechado. A reincidência também impede a aplicação do redutor, a suspensão da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos (não se verificando a exceção do §3º do art. 44 do Código Penal pelo motivo acima exposto) ou a sua suspensão condicional. Neste sentido:

"A agravante obsta o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e, juntamente com a pena corporal, obrigava a fixação do regime inicial fechado e impedia a substituição por restritivas de direitos." TJSP, Apelação n. 0000411-36.2016.8.26.0599, Rel. Des. Vico Manãs, j. 23.05.2018.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição, tendo-se em vista que sua culpabilidade, conduta social e personalidade não indicam que tal medida seja suficiente a atender o aspecto retributivo (imposição de uma sanção ao causador do delito) e o preventivo (estímulo ao cumprimento das normas de conduta) da pena. Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR GINALDO DE JESUS SILVA à pena de reclusão, pelo prazo de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias,, em regime inicial fechado, bem como a 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e não se apurando nada que infirme a periculosidade concreta do acusado, as razões de sua prisão cautelar estão mantidas.

"3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". (...) 5. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes." STJ, Sexta Turma, RHC 86.384/SP, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017.

Aliás, a custódia cautelar em casos análogos tem sido mantida pelos tribunais

superiores:

"3. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado. 4. Na espécie, a custódia cautelar foi mantida para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, caracterizada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder dos agentes - cocaína (13 pinos), crack (53 pedras) e maconha (72 trouxinhas). 5. Ordem denegada." STJ, Sexta Turma, HC 375559/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016.

O tempo de prisão preventiva não autoriza, por hora, qualquer mudança em seu regime prisional.

Condeno os acusados ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Declaro o perdimento de todos os valores e bens apreendidos em favor da União Federal, ainda que não se tenha comprovado a sua habitualidade na prática do tráfico, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Artur Nogueira, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA